

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2999/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายสำราญ สุลไลมาน หรือ สุธโรมารย์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 81

จำเลยขวางลูกกระเบิดชนิดสังหาร เข้าไปในบ้านของผู้เสียหายถูกถ้วยชาม แตก แต่ลูกกระเบิดไม่เกิดระเบิดขึ้นเพราะเหตุชนวนเสื่อมคุณภาพซึ่งเป็นกรณีไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นวัตถุแห่งการกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นได้ และมีใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้โดยเหตุบังเอิญ แต่เป็นเรื่องที่ไม่อาจบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำ จำเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตาม ป.อ. มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 81.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 364, 365(2), 80, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 7, 55, 72, 78 และขอให้ริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ส่วนของกลางให้ริบ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ลงโทษจำคุกจำเลยฐานบุกรุกมีกำหนด 1 ปีฐานมี
ลูกกระเบิดขว้าง 2 ปี ฐานพยายามฆ่า 12 ปี รวมจำคุก 15 ปี คำรับสภาพของจำเลย
ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 10 ปี ริมของกลาง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าในวันเวลาเกิดเหตุ
จำเลยกับผู้เสียหายมีเรื่องทะเลาะกันที่บริเวณหน้าบ้านของผู้เสียหายจริง ปัญหาที่ว่า
จำเลยได้กระทำความผิดดังโจทก์ฟ้องหรือไม่นั้น เห็นว่า สำหรับข้อหาฐานบุกรุก ก่อน
เกิดเหตุผู้เสียหายนั่งดื่มกาแฟอยู่ที่ร้านห่างบ้านผู้เสียหายประมาณ 3 วาจำเลยซึ่งเมา
สุราเดินผ่านมาได้พูดท้าทายให้ผู้เสียหายออกไปต่อยกับจำเลย แต่ผู้เสียหายเห็นว่า
จำเลยเมาสุราจึงมิได้ตอบโต้และได้แนะนำให้จำเลยกับไปนอน จำเลยก็มิได้เชื่อฟัง
กลับเข้ามาต่อຍผู้เสียหาย นางสำเนียง มาศิริ ภรรยาผู้เสียหายได้ยินเสียงโต้เถียงกัน
จึงมาเรียกให้ผู้เสียหายกลับบ้าน ผู้เสียหายกับนางสำเนียงเบิกความว่า จำเลยได้ถือ
มีดโกนติดตามผู้เสียหายกับนางสำเนียงไปและขึ้นบันไดบ้านของผู้เสียหาย ครั้นเมื่อ
นางสำเนียงร้องห้ามมิให้จำเลยขึ้นไป แต่จำเลยไม่ยอมเชื่อจนนางสำเนียงร้องบอก
ชาวบ้านให้ช่วยไปตามตำรวจ จำเลยจึงได้กลับไป ร้อยตำรวจโทวีระชัยกรานคำย ได้
ไปถึงที่เกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุเล็กน้อยผู้เสียหายก็แจ้งต่อร้อยตำรวจโทวีระชัยทันที
ว่า จำเลยใช้มีดโกนไล่ฟันข้อเท็จจริงจึงมีน้ำหนักและเหตุผลให้เชื่อได้ว่า จำเลยได้
กระทำความผิดฐานนี้ดังโจทก์ฟ้อง ส่วนข้อหาในความผิดฐานมีลูกกระเบิดไว้ในครอบ
ครองและความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายนั้น ผู้เสียหายกับนางสำเนียงเบิกความ
ว่า ก่อนจำเลยออกจากบ้านของผู้เสียหายจำเลยได้พูดขึ้นว่า เดี่ยวพบกันซึ่งเป็น
ถ้อยคำที่จำเลยแสดงความอาฆาตผู้เสียหายอยู่ ประมาณ 10 นาทีต่อมา จำเลยได้
กลับไปที่บ้านผู้เสียหายอีก นางสำเนียงจึงให้ผู้เสียหายหลบเข้าไปในบ้าน จำเลยปลด

กระดุมเสื้อล้วงเอาลูกกระเบิดออกมาถอดสลักแล้วขว้างไปบนบ้านของผู้เสียหายถูก ถ้วยชามของผู้เสียหายแตกแต่ลูกกระเบิดไม่ทำงานเมื่อขว้างแล้วจำเลยก็วิ่งหนีไป เมื่อ ร้อยตำรวจโทวีระชัยมาถึงที่เกิดเหตุก็เห็นลูกกระเบิดตกอยู่ 1 ลูก และมีถ้วยชามแตก โดยผู้เสียหายแจ้งว่าก่อนเกิดเหตุได้โต้เถียงกับจำเลยและจำเลยใช้มีดโกนไล่ฟันผู้เสียหายจนต่อมาจึงเอาลูกกระเบิดมาขว้าง หลังจากนั้นจำเลยได้หลบหนีออกจากบ้าน ของผู้เสียหาย ร้อยตำรวจโทกอบกิจจิตต์การุณราชฎ์ ได้สืบสวนติดตามจับจำเลย ตลอดมาจนหลังเกิดเหตุประมาณ 2 ปีเศษ จึงจับจำเลยได้ การหลบหนีของจำเลยจึง เป็นข้อพิรุธของจำเลยประการหนึ่ง ครั้นเมื่อร้อยตำรวจโทกอบกิจกับพวกจำเลยได้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2527 จำเลยก็รับสารภาพทุกข้อหา ปรากฏตามบันทึกการ จับกุมเอกสารหมาย จ.2 ในวันรุ่งขึ้นร้อยตำรวจโทไชยยศจินดาทอง รองสารวัตร สืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนได้สอบสวนจำเลย จำเลยก็ยังคง ยืนยันให้การรับสารภาพตลอดมา และให้การถึงลูกกระเบิดของกลางไว้ด้วยว่าจำเลย ได้เก็บไว้นายแล้วตั้งแต่จำเลยเป็นทหารเสือพราน ปรากฏตามบันทึกคำให้การของผู้ ต้องหาเอกสารหมาย จ.7 ต่อมาในวันที่ 27 มีนาคม 2527 ร้อยตำรวจโทไชยยศได้ให้ จำเลยนำชี้ที่เกิดเหตุและถ่ายภาพการกระทำของจำเลยประกอบคำรับสารภาพ ปรากฏตามบันทึกการนำผู้ต้องหาชี้สองสถานที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพเอกสาร หมาย จ.9 ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า จำเลยได้ให้การรับสารภาพต่อพนักงาน สอบสวนและนำชี้ที่เกิดเหตุด้วยความสมัครใจ ขอนำสืบของจำเลยที่อ้างว่าพนักงาน สอบสวนให้จำเลยลงชื่อโดยมิได้อ่านให้ฟังก็ดี และให้ลงชื่อไว้ในกระดาษที่มีได้พิมพ์ ข้อความไว้ก็ดี ไม่มีน้ำหนักและเหตุผลให้รับฟังเป็นความจริงได้ ข้อเท็จจริงจึงรับ ฟังได้ว่า จำเลยได้มีลูกกระเบิดไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และได้ขว้างลูกกระเบิดเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายจริง ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

สำหรับลูกกระเบิดของกลาง พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน ได้ส่งให้ผู้ชำนาญการพิเศษ กองพลาธิการ กรมตำรวจตรวจพิสูจน์แล้วมีรายงานการ

ตรวจพิสูจน์ตามเอกสารหมาย จ.3 ว่าเป็นลูกกระเบิดกว้างชนิดสังหารแบบอเมริกันทาง
ราชการทหารและตำรวจเรียกว่า ลูกกระเบิดกว้างชนิดสังหารแบบ 88 บ. 67 แต่ลูก
กระเบิดของกลางอยู่ในสภาพใช้ทำการระเบิดไม่ได้เพราะชนวนเสื่อมคุณภาพร้อยละ
ตำรวจเอกคดี จันทรืสดี ประจำแผนกวัตถุระเบิด กองกำกับการ 3 กองพลธิการ กรม
ตำรวจ ผู้ตรวจพิสูจน์เบิกความว่า ลูกกระเบิดของกลางนี้จากการพิสูจน์ปรากฏว่าชนวน
ระเบิดใช้การไม่ได้เพราะเสื่อมคุณภาพและได้ทดลองถอดชนวนจากลูกกระเบิดของ
กลางออกแล้วเอาชนวนไปทดลองปรากฏว่าชนวนเสื่อมคุณภาพ จากรายงานการ
ตรวจพิสูจน์ของกลางประกอบกับคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกคดี จันทรืสดี ผู้
ชำนาญการพิเศษแสดงว่าลูกกระเบิดของกลางไม่อาจที่จะเกิดระเบิดขึ้นได้เพราะเหตุ
ชนวนเสื่อมคุณภาพ ซึ่งเป็นกรณีไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นวัตถุแห่งการกระทำความผิด
ได้และมีใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้โดยเหตุบังเอิญ แต่เป็นเรื่องที่ไม่อาจบรรลุผลได้
อย่างแน่แท้เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
81 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
288 ประกอบด้วยมาตรา 80 นั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้เฉพาะข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นเป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 81 จำคุก 6 ปี คำให้การของจำเลย
ชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์"

(มานะ เพียรสนอง-สินวล คงลาภ-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

1. ข้อพิจารณาทางวิชาการ บทบัญญัติเรื่องการพยายามกระทำความผิดในหมวด 5 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของไทยได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายอาญาของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 23 และ มาตรา 24 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (StGB) ดังนั้นจึงควรศึกษาถึงทฤษฎีกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังของการพยายามกระทำความผิดโดยย่อ เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับความพยายามกระทำความผิด 1.1 โครงสร้างความผิดทางอาญา การพยายามกระทำความผิดชี้ให้เห็นว่าการกระทำนั้นครบองค์ประกอบภายใน (เจตนา) แต่องค์ประกอบภายนอกของความผิดอาญานั้นไม่ครบสมบูรณ์ กล่าวอีกนัยหนึ่งการพยายามกระทำความผิดมีเงื่อนไขว่า ก. ผู้กระทำตกลงใจที่จะกระทำความผิดอย่างไม่มีเงื่อนไข และการตกลงใจดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับองค์ประกอบภายในของความผิดอาญา ข. ผู้กระทำได้เริ่มกระทำการซึ่งเป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งของความผิดอาญา(vgl.H.Otto,GrundkursStrafrecht,AllgemeineStrafrechtslehre, Berlin1976,S.225;H.Welzel,DasDeutscheStrafrecht,10.Aufl.Berlin1967,S.182)

1.2 ทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวกับการพยายามกระทำความผิดที่เป็นไปไม่ได้โดยแน่แท้

1.2.1 ทฤษฎีภาวะวิสัย (DieobjektiveTheorie) ทฤษฎีนี้ยึดถือว่าอันตรายของเจตนากระทำความผิดนั้นจะต้องมีการแสดงออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ก. ทฤษฎีภาวะวิสัยในอดีต Feuerbach และ Mittermaier แยกการพยายามกระทำความผิดที่เป็นไปไม่ได้โดยสมบูรณ์และโดยสัมพัทธ์ (absolutuntauglicherundrelativuntauglicherVersuch) เฉพาะการพยายามกระทำความผิดที่เป็นไปไม่ได้โดยสัมพัทธ์เท่านั้น ที่ผู้กระทำจะต้องรับโทษ ทั้งนี้ศาลจะพิจารณาย้อนไปถึงข้อเท็จจริงทางภาวะวิสัยก่อนการกระ

ทำความเข้าใจ (expost) ทฤษฎีดังกล่าวนี้ศาสตราจารย์จิตติ ตังศภัทย์ ได้เขียนอธิบายไว้ว่า ประการแรก การพยายามไม่สำเร็จโดยเด็ดขาดเกี่ยวกับปัจจัย หมายถึงวิธีการที่การกระทำไม่มีทางที่จะสำเร็จได้เลย เช่น ยิงคนด้วยปืนที่ไม่มีกระสุนบรรจุ หรือจะฆ่าคนโดยวางยาพิษแต่สิ่งที่ผสมไม่ใช่ยาพิษ ประการที่ 2 การพยายามไม่สำเร็จโดยไม่เด็ดขาดเกี่ยวกับหมายถึงวิธีการอาจเกิดผลสำเร็จได้ แต่ผู้กระทำไม่รู้จักรู้จักใช้วิธีการนั้น โดยถูกต้องหรือมีเหตุอื่นมาขัดขวาง เช่น ยิงไม่ถูก เพราะขาดความแม่นยำ ผู้เสียหายหลบทัน หรือใช้เครื่องมือจัดหีบไม่เป็นจึงเปิดไม่ออก (ดู จิตติ ตังศภัทย์ คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตอน 1 หน้า 344) ข. ทฤษฎีภาวะวิสัยในปัจจุบันนี้หรือเรียกว่า "Gefährlichkeitstheorie" v.Liszt และ v.Hippel เห็นว่าการพยายามกระทำความผิดนี้เป็นอันตรายเมื่อวิญญูชนในขณะการทำการนั้น คาดหมายไว้ว่าการพยายามกระทำความผิดนั้นจะเป็นความผิดสำเร็จที่เป็นไปได้ โดยพิจารณาขณะกระทำความผิด (exante) เช่น พยายามฆ่าโดยยิงปืนซึ่งบุคคลที่สามได้ถอดกระสุนปืนออกเสียก่อนแล้ว ถ้าพิจารณาทฤษฎีภาวะวิสัยในอดีต ข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเป็นการกระทำความผิดที่เป็นไปไม่ได้โดยสมบูรณ์ (absolutuntauglicher Versuch) แต่ตามทฤษฎีภาวะวิสัยในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นการพยายามการกระทำความผิดที่เป็นไปไม่ได้โดยไม่ได้แยกว่าจะเป็นไปไม่ได้โดยสมบูรณ์หรือโดยสัมพัทธ์ 1.2.2 ทฤษฎีอัตวิสัย (Diesubjektive Theorie) ทฤษฎีนี้ถือว่าเจตนาที่แสดงออกภายนอกจะเป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยและระเบียบของบ้านเมืองหรือไม่ ไม่ใช่สาระสำคัญ อันตรายดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อผู้กระทำมีเจตนากระทำผิดอาญาและได้มีการเริ่มกระทำการแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะแบ่งแยกว่าการพยายามกระทำความผิดนี้ในทางภาวะวิสัยจะเป็นอันตรายหรือไม่ ด้วยเหตุวัตถุที่กระทำต่อหรือปัจจัยที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้น ไม่อาจทำให้ความผิดสำเร็จได้ การที่ผู้กระทำเข้าใจว่าการกระทำความผิดนั้นมีศักยภาพที่จะเป็นความผิดสำเร็จได้ก็เพียงพอแล้ว เช่น การพยายามแทงลูกด้วยปัจจัยที่ไม่อาจบรรลุผลได้ หรือหญิงที่เป็นวัตถุแห่งการกระทำนั้น

ไม่มีกรรม (RG1,439;17,158) หรือการพยายามทำแท้งด้วยปัจจัยที่ไม่อาจบรรลุผล
ได้ กับหญิงที่ไม่มีกรรม (RG34,217) หรือการพยายามฆ่าศพ (RG1,451) หรือการ
ฉ้อโกงหรือเรื่องที่ตนมีสิทธิเรียกร้อง (RG42,92) ทั้งนี้รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ
ของผู้อื่น แต่ไม่มีเงินในกระเป๋า หรือการยิงไปบนเตียงโดยเข้าใจว่าบุคคลซึ่งตนจะฆ่า
นั้นนอนอยู่บนเตียง แต่ความจริงแล้วไม่มีผู้ใดนอนอยู่ ทฤษฎีภาวะวิสัยเป็นผลมาจาก
คำสอนเรื่องสาเหตุของการพยายามกระทำความผิด ทำนองเดียวกับกรณีความผิด
สำเร็จที่ละเมิดต่อสิ่งที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง(einekausaleRechtsgutsverletzung)
ความผิดฐานพยายามกระทำความผิดก็เป็นอันตรายต่อสิ่งที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองเช่น
กัน (einekausale Rechtsgutsgefährdung) โดยเน้นความสำคัญที่การละเมิด
กฎหมายโดยการแสดงเจตนาออกมาทางภาวะวิสัย (ausserlichabjektiv) ในขณะที่
ทฤษฎีอัตตวิสัยเน้นความสำคัญของระเบียบระเบียบแบบแผนทางกฎหมายในการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้านจิตใจของประชาชน ดังนั้นระเบียบแบบแผนทางกฎหมายจึงถูก
ละเมิดโดยเจตนากระทำความผิด เมื่อมีการกระทำตามเจตนาดังกล่าวเกิดขึ้นและ
การกระทำที่มีศักยภาพให้เกิดความผิดสำเร็จนั้นเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ใน
ที่นี้หมายถึงการกระทำที่พ้นขั้นตอนของการเตรียมกระทำความผิดแล้ว ทฤษฎี
ในเรื่องการพยายามกระทำความผิดและการพยายามกระทำความผิดที่เป็นไปไม่ได้
โดยแน่แท้เหมือนกัน ต่างกันตรงระดับของความร้ายแรง การพยายามที่มีศักยภาพ
ใกล้ความผิดสำเร็จมากเท่าใด ความร้ายแรงของแรงทำความผิดทางอาญาก็ยิ่งมีมาก
ขึ้นเท่านั้น 1.3 คำสอนเรื่องการขาดองค์ประกอบ

(Dersog.MangelamTatbestand)ตามคำสอนของ Frank และ Dohna แยกเรื่องการ
ขาดองค์ประกอบความผิดออกจากเรื่องการพยายามกระทำความผิด โดยถือว่าวัตถุที่
มุ่งกระทำต่อหรือองค์ประกอบภายนอกที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดไม่ครบถ้วน
เช่น ถ้าผู้กระทำเอาทรัพย์สินของตนไป โดยเข้าใจว่าเป็นทรัพย์สินของผู้อื่น หรือหญิงที่ไม่มี
กรรมเจตนาที่จะทำการแท้งลูก กรณีไม่ใช่การพยายามกระทำความผิดแต่เป็นการ

ขาดองค์ประกอบ คำสอนดังกล่าวนี้ไม่ต้องตามแนวคำพิพากษาของศาลเยอรมันตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ศาลเยอรมัน (Reichsgericht และ Bundesgerichtshof) ถือว่าการพยายามกระทำความผิดคือการแสดงเจตนาที่จะกระทำความผิดที่เป็นไปไม่ได้โดยแน่แท้ (RG18,198(200f.))

(vgl.H.Welzel,a.a.O.,s.185;H.H.Jescheck,LehrbuchdesStrafrechts AllgemeinerTeil,2.Aufl1972,S.400-

401;H.Blei,StrafrechtsIAllgemeinerTeil,16.AuflMunhen1975,S.201-204)

ศาสตราจารย์จิตติ ดิงศรัทีย มีความเห็นเช่นเดียวกับ Frank และ Dohnaโดยย่อมารับ เรื่องการขาดองค์ประกอบความผิดว่า ถ้ายังต่อไม่โดยเข้าใจว่าเป็นคนที่ผู้กระทำ ประสงค์จะฆ่า ดังนี้ตัวคนที่ผู้กระทำประสงค์จะฆ่านั้นมีอยู่ องค์ประกอบความผิดมีครบบริบูรณ์และวัตถุที่ยังเป็นต่อไม่จึงไม่บรรลุผลโดยแน่แท้ ตามมาตรา 81 แต่ถ้ายัง ศพผู้ที่ต้องการฆ่าต้องถือว่าขาดองค์ประกอบความผิด (ดู จิตติดิงศรัทีย, คำอธิบาย ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตอน 1,หน้า 135) ปัจจุบันนี้คำสอนเรื่องการขาดองค์ ประกอบความผิดไม่เป็นที่ยอมรับในกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำพิพากษาของศาล(vgl.H.H.Jescheck,a.a.O.,s401) ตามแนวคำ พิพากษาของศาลเยอรมันถือว่าในการปล้นทรัพย์ แต่ปรากฏว่าเหยื่อที่จะถูกปล้นไม่ ปรากฏตัว เป็นความผิดฐานพยายามปล้นที่เป็นไปไม่ได้โดยแน่แท้

(BGH,NJW1952,514) ในการวางยาพิษผู้อื่นโดยมีเจตนาฆ่า แต่ยาพิษน้อยเกินไป เป็นความผิดฐานพยายามฆ่า (BGH11,324) และเข้าใจว่าทรัพย์ที่ตนรับซื้อมานั้นเป็น ทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด แต่ความจริงแล้วหาใช่ทรัพย์ที่ได้มาจากการก ระทำความผิดไม่ ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นความผิดฐานพยายามรับของโจร

(RG64,130(132)) 2. แนวคำพิพากษาศาลฎีกาของไทยได้แยกพิจารณาความแตก ต่างระหว่างการพยายามกระทำความผิดตาม มาตรา 80 และการพยายามกระทำ ความผิดที่เป็นไปไม่ได้โดยแน่แท้ตาม มาตรา 81 ดังนี้ 2.1 ในประเด็นเหตุบังเอิญที่

ความผิดนั้นไม่อาจสำเร็จได้ เป็นการพยายามกระทำความผิดตาม มาตรา 80 เช่นปีน
บรรจุกะสุน แต่กระสุนด้านเพราะเสื่อมคุณภาพหรือเพราะเหตุอื่นใดไม่ปรากฏ (คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 980/2502)หรือกระสุนปืนไม่ลั่นเพราะคุณภาพไม่ดีหรือเหตุอื่นใด
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 711/2513) แม้จะยิงด้วยกระสุนปืนลูกนั้นมาแล้ว 3 ครั้ง
กระสุนปืนไม่ลั่น การยิงครั้งที่ 4 ก็ยังไม่เป็นการกระทำที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่าง
แน่แท้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 783/2513) ยิงด้วยปืนคาบศิลาสับนกดินปืนไม่ลุก(คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 608,609/2458,619/2469,1087/2480,1434/2498)กระสุนขัดลำ
กล้อง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 189/2477,55/2515) ปลอกกระสุนที่ยิงแล้วค้างอยู่ยิง
อีกไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 635/2486) ประชากรลูกเลื่อนไม่ถึงที่ กระสุนไม่ขึ้น
ลำ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 556/2502) ยิงปืนลูกม่ไปตรงช่องที่ไม่ได้บรรจุกระสุน
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 280/2515) 2.2 ข้อเท็จจริงที่ศาลฎีกา วินิจฉัยว่าเป็นการ
พยายามกระทำความผิดที่เป็นไปไม่ได้โดยแน่แท้ ตามมาตรา 81 นั้น เช่น เข็มแทง
ชนวนไม่แรงพอไม่สามารถทำให้กระสุนปืนลั่นได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 421/2516)
กระสุนปืนทำเองไม่ร้ายแรง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 727/2496,744/2497,
821/2497,1678/2498) ขว้างขวดระเบิดไปยังกลุ่มคน แต่กำลังอ่อนไม่ทำให้คนตาย
ได้โดยแน่แท้ ซึ่งวิญญูชนหรือจำเลยต้องทราบว่าเป็นวัตถุร้ายแรงทำให้ตายได้ เป็น
เจตนาฆ่าตาม มาตรา 81(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1720/2513) ตามแนวคำพิพากษา
ศาลฎีกาดังกล่าวข้างต้น อนุมานได้ว่าข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการกระ
ทำความผิดที่จะปรับเข้ากับองค์ประกอบภายนอกของความผิดอาญามีศักยภาพทำให้
ความผิดสำเร็จลงได้ แต่เนื่องจากเหตุบังเอิญความผิดจึงไม่สำเร็จกรณีเป็นพยายาม
กระทำความผิดตาม มาตรา 80 แต่หากข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการกระ
ทำความผิดไม่มีศักยภาพที่จะทำให้การกระทำความผิดนั้นสำเร็จลงได้ เช่น ระเบิด
ขวดที่ใช้ขว้างมีกำลังอ่อนกรณีเป็นพยายามกระทำความผิดที่เป็นไปไม่ได้โดยแน่แท้
ตาม มาตรา 81 3. สำหรับข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ (คำพิพากษาศาล

ฎีกาที่2999/2530)"จำเลยขวางถูกระเบิดชนิดสังหารเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายถูก ถ้วยชามแตก แต่ถูกระเบิดไม่เกิดระเบิดขึ้นเพราะเหตุชนวนเสื่อมคุณภาพ"ถูกระเบิด ชนิดสังหารเป็นปัจจัยที่ใช้ในการกระทำความผิดซึ่งมีศักยภาพที่จะทำให้คนตายได้ หากจะยึดแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวข้างต้นผู้เขียนเห็นว่ากรณีน่าจะเป็นการ พยายามกระทำความผิดตาม มาตรา 80 เช่นเดียวกับที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัย ที่ศาล ฎีกาวินิจฉัยว่า "มิใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้โดยเหตุบังเอิญ" แต่เป็นเรื่องที่ไม่อาจรู้ผล ได้อย่างแน่แท้เพราะปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 81" นั้นผู้เขียนเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 81 เป็นเรื่องการพยายามกระทำ ความผิดที่เป็นไปไม่ได้ หรือไม่อาจบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ส่วนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 เป็นการพยายามกระทำความผิดที่ความผิดสำเร็จนั้นเป็นไปได้ แต่ศาลฎีกา ได้วางแนววินิจฉัยในคำพิพากษาคับก่อน ๆ ว่าการกระทำความผิดซึ่งปัจจัยที่ใช้ใน การกระทำนั้นมีศักยภาพที่จะทำให้ความผิดนั้นสำเร็จได้ตามเจตนาของผู้กระทำ แต่ เนื่องจากเหตุบังเอิญจึงทำให้ความผิดนั้นไม่สำเร็จ เป็นการพยายามกระทำความผิด ตาม มาตรา 80 แนวบรรทัดฐานในเรื่องเหตุบังเอิญดังกล่าวของศาลฎีกาไทยนี้ เป็นการพัฒนาหลักกฎหมายไปอีกแนวทางหนึ่งซึ่งแตกต่างไปจากแนวคำสอน กฎหมายอาญาของประเทศเยอรมัน กมลชัยรัตนสกาวงศ์.